

1523992-98.2019.8.26.0114

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Nelson Augusto Bernardes de Souza

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... forma, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu. Ele tinha em depósito para fins de tráfico, 25 porções de cocaína, substância entorpecente (droga), sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os guardas municipais afirmaram que durante patrulhamento no local dos fatos, avistaram o réu em atitude típica do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

3ª Vara Criminal

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Bloco "D" - sala 38 - Jardim Santana

CEP: 13088-901 - Campinas - SP

Telefone: (19)-3756-3727 - E-mail: campinas3cr@tjsp.jus.br

1523992-98.2019.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1523992-98.2019.8.26.0114

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Averiguado:

FABIO DE PAULA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

Fabio De Paula Da Silva foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que no dia 21 de agosto de 2019, por volta das 10h13min, na Rua Prata, altura nº 65, bairro Vila Rica, nesta cidade, FABIO DE PAULA DA SILVA tinha em depósito, para fins de tráfico, 25 (vinte e cinco) invólucros plásticos contendo cocaína, pesando 16,1g (dezesesseis gramas e um decigrama), substância entorpecente (droga), sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 102/105) e apresentou Defesa Prévia (fls.112/113). A denúncia foi recebida (fls. 93) e o réu foi devidamente citado (fls. 174). Regularmente processados os autos, realizou-se audiência VIRTUAL, conforme permissão da Resolução nº 314 e 329 de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, e dos Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020 do TJSP, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, e o réu interrogado. Ao final, as partes apresentaram seus

memoriais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade arguida pela defesa técnica do réu. Nota-se que o acusado foi notificado por edital em 27/05/2021 (fls. 105), uma vez que não localizado para ser notificado pessoalmente. A Defensoria Pública foi nomeada e apresentou Defesa Prévia (fls. 112/113). Em seguida, a denúncia foi recebida em 16/06/2021, sendo determinada a citação do réu por edital (fls. 120). Transcorrido o prazo do edital, foi decretada a revelia do réu nos termos do artigo 366 do CPP, determinando-se a suspensão do curso processual. Importante anotar que, diferentemente do alegado, o acusado não estava preso durante o transcurso do prazo do edital, que foi disponibilizado no DJE em 08/01/2021 (fls. 104). Assim, não há que se falar em nulidade.

No mérito, o pedido inicial é procedente.

As provas carreadas aos autos indicam que o réu praticou o delito de tráfico de drogas que lhe é imputado.

Vejamos.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 8/10 pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls.11/12 e pelo Auto de Exame químico-toxicológico de fls. 20/21, positivo para cocaína.

Quando interrogado, em Juízo, o réu negou os fatos. Afirmou que estava no local apenas para consumir a cocaína, uma vez que é usuário. Afirmou que estava na posse de uma porção de cocaína e R\$ 14,00 em dinheiro.

A negativa, do réu, em Juízo, restou isolada e desmentida pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O Guarda municipal João Carlos Aparecido dos Santos, em Juízo, afirmou que em estava efetuando patrulhamento pelo local dos fatos, quando se deparou com Fábio entregando algo para um motoqueiro que estava no local, que se evadiu para local ignorado. Aduziu que, neste momento, Fábio adentrou em uma residência que fica ao lado do nº 65 e, passados alguns instantes, saiu, momento em que foi abordado pela guarnição. Disse que na posse de Fábio havia R\$14,00 em espécie e um aparelho celular Samsung. Contou que ao ser indagado, Fábio informou que estava no local vendendo entorpecentes, indicando o local onde estava guardado o entorpecente para venda, sendo localizadas as 25 porções de um pó branco análogo à cocaína, além do valor de R\$175,00. Narrou que foi acionado o apoio do Canil para ajudar na procura de mais entorpecentes, porém nada mais foi encontrado, motivo pelo qual conduziram o investigado e material arrecadado até a delegacia.

No mesmo sentido foi o depoimento do guarda municipal Luis Roberto Pereira de Jesus, em Juízo.

Dessa forma, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu. Ele tinha em depósito para fins de tráfico, 25 porções de cocaína, substância entorpecente (droga), sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os guardas municipais afirmaram que durante patrulhamento no local dos fatos, avistaram o réu em atitude típica do tráfico de drogas, ou seja, entregando entorpecente a um usuário e recebendo dinheiro em troca. Aduziram ter sido o réu abordado, havendo em seu poder R\$14,00 em espécie e um aparelho celular Samsung.

Disseram que indagado, o acusado confessou que comercializava entorpecentes, indicando, inclusive, o local onde estava a droga, tendo a equipe localizado 25 porções de um pó branco análogo à cocaína no local indicado pelo réu, além do valor de R\$175,00.

Lado outro, a quantidade de droga encontrada (25 flaconetes de cocaína pesando 16,1g), além do local onde o réu estava e as circunstâncias da prisão, indicam a finalidade da mercancia ilegal. Nenhum usuário, a princípio, porta tanta droga para consumo próprio.

Não se pode desmerecer os depoimentos dos Guardas Municipais. São eles agentes do Estado incumbidos de reprimir a criminalidade. Quando prestam depoimentos uníssonos, coerentes e seguros, sem que haja motivo para acreditar que querem incriminar pessoa inocente, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório. Entender diversamente, invalidando a prova oral simplesmente por ter sido fornecida por policiais seria desprezar a atividade policial, com consequente aumento da impunidade, já que diversos crimes têm apenas policiais como testemunhas.

Neste sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL JUDICIAL APTA A MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime de lesão corporal de natureza leve. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado à espécie. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10). Improvimento do recurso defensivo. (TJ-SP - APL: 00069180720138260344 SP 0006918-07.2013.8.26.0344, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 02/03/2016, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 08/03/2016) - (Grifei).

Eventuais e pequenas contradições quanto a fatos secundários nos relatos policiais são irrelevantes e normais. O que importa para a rigidez da prova é a coesão das versões em seu conteúdo principal.

A negativedo réu restou isolada nos autos e, embora tenha afirmado estar sendo injustamente acusado pelos guardas que efetuaram sua prisão, não apresentou provas, nem sequer indícios de que sua alegação fosse verdadeira. Desta forma, não é crível que agentes do Estado tenham acusado injustamente o réu, sem sequer conhecê-lo anteriormente.

Não pode ser acolhida a tese defensiva de nulidade das provas produzidas, em razão de ter a abordagem sido realizada por guardas municipais, que, segundo a defesa, não possui atribuições das polícias civis e militares, como abordagem de pessoas e buscas pessoais. Não se desconhece o julgamento da Sexta Turma do Tribunal Superior De Justiça, REsp 1.977.119, em que as provas produzidas, naquele caso e contexto, foram consideradas ilícitas. Entretanto, trata-se de questão ainda não pacificada no STJ e já referendada pelo TJSP. Nesse sentido:

Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Rejeição da denúncia - Recurso do Ministério Público que almeja o seu recebimento Possibilidade. Apreensão das drogas feita por guardas municipais. Não há ilicitude na conduta dos agentes públicos, que presenciam crimes na prática de suas funções. Ademais, não se pode considerar que o recebimento de uma denúncia anônima, como no caso dos autos, caracteriza-se de ato investigatório, pois se depreende que os guardas estavam próximos do local da prática do delito, sendo certo que apenas continuaram o percurso que faziam, de modo que não foi realizada investigação, campana ou qualquer outra conduta que traria ilicitude ao presente caso. Tal ato não se compara com uma denúncia anônima recebida na Delegacia, que repassa aos agentes públicos para então irem à busca dos criminosos ou, muito menos, com uma indicação que leva os policiais a efetuarem interceptações telefônicas ou longas campanhas E, ainda, qualquer um do povo pode prender quem estiver em flagrante, lembrando que o crime de tráfico tem natureza permanente - Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade para o recebimento da denúncia Recurso provido. (Recurso em Sentido Estrito 1500390-78.2021.8.26.0544, 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, relator FREITAS FILHO, 06/08/2021).

Assim, respeitadas as razões defensivas, o requerimento não pode ser acolhido.

Em face das provas produzidas, inviável o acolhimento das teses defensivas e a desclassificação para porte de entorpecente e, comprovadas autoria e materialidade delitivas, de rigor a procedência do pedido inicial.

Passo a dosar a pena.

Atento aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, anoto que a atenuante da menoridade não pode trazer a pena-base aquém do mínimo legal. Não há agravantes, o réu é primário (fls. 202).

Na terceira fase, sendo o acusado primário e não havendo indicação de que integre organização criminosa, além de não haver qualquer prova no sentido de que ele se dedique ao tráfico de forma contumaz e permanente, considerando, ainda, que a quantidade de entorpecente com ele encontrada não é expressiva e/ou diversificada, nos termos do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343, reduzo a sua pena em 2/3 (dois terços) resultando, em definitivo, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Cabe destacar que em caso análogo, no qual o réu transportava cerca de 990 gramas de cocaína, houve determinação do STF, em sede Recurso Ordinário de Habeas Corpus n. 197905, para aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06. Há vários outros precedentes desta Corte e do STJ neste sentido, ou seja, quantias mais expressivas de droga com o reconhecimento do privilégio.

Também decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DOS

ENTORPECENTES APREENDIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PERMITEM AFERIR A DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA E, PORTANTO, NÃO SE PRESTAM PARA JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAR A FRAÇÃO DESSE BENEFÍCIO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da atual jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, fixada, quando do julgamento do RESP n. 1.887.511/SP, a elevada quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do Acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas. Portanto, inexistentes outras características da conduta deletéria aptas a amparar conclusão nesse sentido, tal como ocorreu na espécie, não há falar em afastar o benefício ou modular a fração dessa aquém do mínimo legal. 2. Agravo regimental desprovido.". (STJ: RECURSO ESPECIAL Nº 1925096 , julgado em 17/08/2021)" - grifei

No mesmo sentido decidiu o TJSP, em julgamento de caso originado nesta Vara Criminal, apreensão de 5,77 kg de maconha ao dispor que: "Porém, em que pese estivesse o réu a transportar expressiva quantidade de droga, quase seis quilos, a prova produzida na instrução nada revelou quanto ao envolvimento dele com organização criminosa ou que se dedicasse com habitualidade à prática de crimes, motivo pelo qual cabe aplicar a redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, adotando-se o índice de um sexto, considerada a quantidade do entorpecente, que permitiria atingir grande número de usuários, de tal modo a se alcançar um total definitivo de quatro anos e dois meses de reclusão e quatrocentos e dezesesseis dias-multa, no piso mínimo, o que inviabiliza a imposição de sanções alternativas, as quais, na hipótese, nem seriam socialmente recomendáveis" (Apelação Criminal 1500824-89.2020.8.26.0548; Relator: Mário Devienne Ferraz; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/12/2020) - grifei.

Por fim, em caso análogo, também em julgamento de caso originado nesta Vara Criminal, apreensão de 838 porções de cocaína, decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo: "Tráfico de drogas Materialidade e autoria demonstradas - Conjunto probatório satisfatório - Pena-base fixada no mínimo - Confissão do réu - A quantidade de drogas somente deve ser considerada na primeira fase de aplicação da pena e não impede a aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Regime aberto Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e multa - RECURSO DA DEFESA PROVIDO" (Apelação Criminal 1501577-46.2020.8.26.0548; Relator: Heitor Donizete De Oliveira ; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19 de outubro de 2021) - grifei.

Por fim, vale transcrever recente decisão do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 48,5 G DE COCAÍNA, 298,7 G DE LANÇA-PERFUME, 114,1 G DE MACONHA, 11,3 KG DE LANÇA PERFUME (GALÃO), 1.471,2 G DE COCAÍNA, 6.662,7 G DE MACONHA (TIJOLO), 1.014 G DE MACONHA, 80,2 G DE MACONHA, 72 G DE MACONHAS, 08 G DE COCAÍNA (EPENDORF) E 586,8 G DE LANÇA PERFUME (FRASCO). PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PRÉ-QUESTIONAMENTO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PACIENTE PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES. REGIME ABERTO E PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. Ordem parcialmente concedida nos termos do dispositivo. (HC Nº 731.698 - SP - 2022/0085932-2, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 06/06/2022, Superior Tribunal de Justiça) - grifei.

O dia-multa valerá o mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o réu FABIO DE PAULA DA SILVA a cumprir pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no patamar mínimo,

por ter violado o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista o montante da pena fixado e, também, levando em consideração tratar-se de tráfico privilegiado e de pequenas proporções, será o ABERTO. Poderá o acusado aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.

Ainda, anoto ser possível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Justifico.

O Supremo Tribunal Federal (HC 97.256) reconheceu a inconstitucionalidade da parte final do artigo 44 da lei 11.343/06 (...vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos). Vale frisar, inclusive, que a Corte maior no julgamento do HC 111.840 declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º, do artigo 2º, da Lei 8.072/90, o qual prevê que a pena para o crime de tráfico será cumprida inicialmente em regime fechado. Vale citar alguns julgados sobre o tema: "(...) a partir do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do referido HC nº 97.256/RS, em que se admitiu a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, impõe-se, neste caso, a adequação também do regime, a fim de que sejam observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da sanção penal, com a fixação de regime prisional mais brando, compatível com a benesse concedida justamente para evitar o encarceramento" (STJ, HC nº 237.074/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08.5.2012). "Nesse contexto, nas hipóteses em que se verificar a viabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em medida restritiva de direitos, não deve existir impedimento para a fixação do regime inicialmente aberto no cumprimento da pena." (STJ, HC 213.288/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 22.5.2012). "(...) a Sexta Turma desta Corte adotou o entendimento de que, ante o quantum de pena aplicado, é possível a fixação do regime semiaberto ou o aberto para o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, em conformidade com previsto no art. 33 do Código Penal (HC nº 118.776/MG, da relatoria do Ministro Nilson Naves, julgado em 18.3.2010), bem como a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos." (STJ, HC nº 189.931/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 22.5.2012). "Ocorre que, em recentes julgados, esta Segunda Turma concedeu a ordem a pacientes condenados pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com afastamento da regra do art. 2º, §1º, da Lei. 8.072/1990 (redação dada pela Lei 11.464/2007), que determina o cumprimento no regime inicial fechado, para permitir-lhes que iniciem o cumprimento das suas reprimendas no regime aberto, porque presentes, no caso concreto, os requisitos previstos no art.33, II, c, do Código Penal" (STF, HC 109.343/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, v.u., j.03.4.2012)".

Mais recentemente, o STF reconheceu no julgamento do Habeas Corpus 125.188 a possibilidade de concessão de regime aberto com substituição da pena corporal pela restritiva em casos de tráfico privilegiado. Ainda, é importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 600, analisado sob o rito dos recursos repetitivos, assentou entendimento, aliando-se ao que foi decidido pelo STF no HC 118.533/MS, que o tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo.

Assim, ante tais decisões da Corte Suprema e do STJ, o magistrado deve analisar, caso a caso, os requisitos legais para a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos, especificados no artigo 44 do Código Penal. Dispõe o inciso VI do mencionado artigo ser possível a substituição quando todas as circunstâncias previstas forem favoráveis, inclusive culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime. Não se olvide que o tráfico de drogas é o tipo de crime em que seus agentes estão sempre escalonados em hierarquia que vai dos pequenos traficantes de rua aos grandes chefes que comandam uma organização. Assim, é necessário aferir, no caso concreto, qual a situação exata do condenado.

No caso em tela, verifica-se ser o tráfico apurado de pequenas proporções, não sendo expressiva a quantidade de droga apreendida. Ainda, não há prova de que a sentenciada integre organização criminosa e seja dela membro importante ou ocupante de função de relevo. Por fim, foi reconhecido o tráfico privilegiado. Portanto, possível a substituição da pena corporal ante o preenchimento de todos os requisitos legais.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistentes em prestação de serviço a comunidade pelo tempo da condenação e prestação pecuniária de um salário mínimo a uma entidade assistencial a ser indicada pelo juízo da Execução.

Por fim, anoto que se a situação concreta do condenado e as circunstâncias do crime fossem outras, a fixação da pena e a substituição poderiam não ter ocorrido.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu, se o caso.

Custa na forma da lei. Decreto a perda dos valores apreendidos.

Após o trânsito em julgado, intime-se o réu para o pagamento da multa e expeça-se guia para início da execução.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Campinas, 31 de outubro de 2022.

NELSON AUGUSTO BERNARDES DE SOUZA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA